

1501207-66.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... vinculada à criminalidade organizada, afastando-se a figura do tráfico privilegiado.

Neste sentido, a Constituição Federal reserva tratamento especialmente severo ao tráfico ilícito de entorpecentes nos artigos 5º, inc. XLIII e LI, e artigo 243, parágrafo único.

Assim, a impossibilidade de se aplicar a substituição ao grave crime de tráfico ilícito de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

1501207-66.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501207-66.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164935/2021 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 18569991 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2229/21/111 - 03º D.P.

S.BERNARDO DO CAMPO, 2164935 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN HENRIQUE ANTUNES MARTINS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

JONATHAN HENRIQUE ANTUNES MARTINS (aditamento para correção do nome a pág.183) e ROBERT JOSÉ DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 17 de junho de 2021, por volta das 15h15, na Rua Austrália, altura do numeral 81, Independência, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, previamente ajustados, com unidade de designios e identidade de propósito entre si, vendiam, guardavam e traziam consigo, para fins de mercancia ilícita de drogas e entrega ao consumo de terceiros, 36 (trinta e seis) eppendorfs contendo 21,3g de cocaína e 99 (noventa e nove) eppendorfs contendo 19,7g de cocaína, na forma de crack, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls.42/43), laudo de constatação (fls. 45/47) e laudo de exame químico-toxicológico às págs.142/144, além da quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) em espécie proveniente do comércio espúrio.

ROBERT JOSÉ DA SILVA também foi denunciado e processado como incurso nos artigos 331 e 129, caput, ambos do Código Penal, porque em 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque nas mesmas circunstâncias de tempo e local, desacatou os funcionários públicos Fabiano Dias Pereira e Fabio Roberto de Oliveira, policiais civis, no exercício de suas funções e em razão delas, bem como ofendeu a integridade corporal e a saúde do policial civil Fabio Roberto de Oliveira, causando-lhe as lesões corporais atestadas às págs.149/150.

Segundo o apurado, nas circunstâncias acima mencionadas, policiais civis realizavam a operação "NarcoBrasil" deflagrada para coibir e combater o comércio espúrio. Para tanto, rumaram-se a um conhecido ponto de tráfico de drogas estabelecido na Rua Austrália, numeral 81, Bairro Independência, nesta urbe. Durante breve campanha, os policiais observaram os acusados e um comparsa em atitude típica de traficância, eis que um deles recebia quantia em dinheiro do usuário, o segundo retirava a droga debaixo de um veículo Ford/Verona e a entregava para o comprador. O terceiro indivíduo exercia a função de vigia. Diante da situação supracitada, os policiais aproximaram-se dos réus e do comparsa para realizar a abordagem. Contudo, eles evadiram-se rapidamente do local. Durante a fuga, JONATHAN dispensou próximo aos seus pés certa quantidade de crack. Os policiais foram ao encalço deles e conseguiram deter JONATHAN e ROBERT. Realizada a abordagem, os policiais localizaram no interior do bolso de JONATHAN a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) em espécie proveniente do tráfico de drogas. Após a abordagem, os milicianos diligenciaram nas imediações do local dos fatos, especialmente debaixo do veículo Ford/Verona, que foi utilizado pelos acusados para guardar as drogas, local em que localizaram vasta quantidade e variedade de cocaína e crack, embaladas de forma individual e prontas para o comércio espúrio. Assim, JONATHAN e ROBERT foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia. Ocorre que durante o percurso até a sede policial, ROBERT passou a ameaçar e ofender os policiais com palavras de baixo calão. Assim agindo, ROBERT ofendeu os policiais civis com a evidente intenção de humilhar e desprestigiar a função exercida por eles.

Não bastasse, ao chegarem na Delegacia de Polícia, ROBERT demonstrou agressividade e passou a esmurrar as paredes da custódia em que estava detido. No momento em que ROBERT foi realizar a identificação datiloscópica (providência formal da prisão), ele tentou tomar a arma de fogo do policial Fabio Roberto de Oliveira, agredindo-o fisicamente, causando lesões comprovadas nos autos às págs.149/150. Diante da situação, foi necessária a utilização de força moderada para conter ROBERT. Considerando a vasta quantidade e variedade de droga apreendida, a quantia em dinheiro, a forma de acondicionamento das drogas – em embalagens individuais, prontas para a venda e consumo de terceiros e as circunstâncias pela qual se deu a

prisão em flagrante, não há dúvidas de que a posse das drogas tinha por finalidade o tráfico.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial a págs. 09/100. Notificados (págs.158 e 160), os acusados ofertaram defesa preliminar a pág.167. Recebida a denúncia às págs.168/169, os réus foram citados às págs.189 e 191. Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, interrogando-se os réus.

Em debates, o Ministério Público requer a condenação dos réus, afastando-se, apenas em relação ao réu Robert, o delito de desacato (falta de provas). Postula a elevação da reprimenda, reconhecimento da reincidência dos réus e confissão de Jonathan, afastamento do tráfico privilegiado e a fixação de regime fechado. A defesa postula pela absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece parcial acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares do delito de tráfico de substância entorpecente praticado pelos acusados, inexistindo dúvida quanto à autoria.

Todavia, diante da insuficiência probatória, a absolvição de ROBERT em relação aos crimes de desacato e lesão corporal dolosa é de rigor.

A materialidade do crime de tráfico de droga está demonstrada no auto de exibição e apreensão às págs.42/43 (dinheiro e droga); nos laudos de constatação (págs.45/47), químico-toxicológico (págs.142/144) e no comprovante de depósito juntado às págs.97/98.

Quanto à autoria, na fase policial o acusado JONATHAN confessou a prática do delito nos termos da denúncia (págs.16/17):

"estava no local dos fatos efetuando a venda de entorpecentes (crack), pois está desempregado e não tem como se sustentar, quando avistou um policial vindo em sua direção. Nesse momento, jogou fora o entorpecente para tentar fugir da ação policial, sem obter êxito. Ao ser detido, confirma que tinha R\$ 30,00 (trinta reais) no seu bolso direito da blusa de moletom, oriundo da venda de crack. (....) Por fim, o interrogado ressalta que não conhece pessoalmente ROBERT, mas ele estava no local vendendo drogas...".

Em Juízo, manteve a confissão, embora tenha alterado detalhes da dinâmica e afastado a participação do corréu Robert:

Trabalhava como 'olheiro' na 'biqueira', observando o movimento, organizado a fila e servindo os usuários. O 'pote' (droga) estava sob responsabilidade do menor de idade responsável pela venda, o qual escondia as porções de substância entorpecente na roda de um carro. Robert, usuário, estava na fila aguardando a entrega e droga, juntamente com outros dois usuários.

Em dado momento, um indivíduo bem vestido aproximou-se. Em seguida, sacou a arma de fogo e deu voz de prisão. O menor traficante dispensou a droga e correu, conseguindo fuga por estar mais distante. Também fugiu, mas foi abordado já em rua diversa, com R\$30,00 no bolso. No trajeto, dispensou duas pedras de crack que estavam em seu poder, apreendidas pelos policiais.

Foi colocado pelos policiais civis na viatura. Dirigiram-se à biqueira onde Robert e os outros dois usuários ainda aguardavam na fila. Foram abordados e apenas Robert tinha antecedente criminal, razão pela qual não foi dispensado. O policial chamou Robert de 'folgado' e o colocou na viatura, onde o corréu permaneceu 'resmungando' diante da injusta prisão. Dizia que era assaltante e havia bebido por ter brigado com a mulher. Não ouviu xingamentos e ameaças.

Trata-se de réu confesso, na presença de Magistrada e sob o pálio de todas as garantias constitucionais.

Sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui a confissão elemento seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.

Representa, pois, dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-

la.

De outra parte, não é crível a dinâmica ofertada por Jonathan em relação ao comparsa. Ora, inverossímil a alegação de que Robert e outros dois usuários tenham optado por permanecer no ponto de droga após policial civil dar voz de prisão e iniciar a perseguição dos traficantes.

Sequer esta foi a versão ofertada por ROBERT em Juízo. Com efeito, após a opção pelo silêncio na fase policial (pág.28), em Juízo o réu negou a sua participação no delito de tráfico de droga e apresentou diversa dinâmica:

Foi à 'biqueira' comprar droga. Entregou dinheiro ao traficante, que a buscava em estacionamento de conjunto habitacional ali existente. Aguardava a droga com outros usuários quando os policiais civis chegaram no local. JONATHAN avisou o outro traficante, que estava em poder das drogas e fugiu, dispensando-as. Foi abordado pelos policiais e, alcoolizado, discutiu com eles, razão pela qual foi preso. Na Delegacia de Polícia, foi agredido gratuitamente por três policiais civis.

Algemado, não conseguiu reagir.

A negativa de autoria de ROBERT ficou isolada nos autos pelo mais da prova colhida em instrução.

Sob o crivo do contraditório, os policiais civis Fabiano Dias Pereira e Fabio Roberto de Oliveira, em relato coeso e harmônico com o anterior, informaram os passos da diligência encetada na data do fato e espancaram qualquer dúvida acerca da existência do crime:

O local é conhecido ponto de tráfico de droga. Na data do fato, realizavam operação no local para coibir e combater o comércio espúrio.

Durante breve campana, os policiais observaram os acusados e um comparsa em atitude típica de mercancia ilícita. Recebiam algo do usuário, dirigiam-se a um veículo Ford/Verona que estava próximo deles e a entrega algo para o comprador.

O policial Fabiano declarou ter presenciado JONATHAN recebendo dinheiro dos usuários e ROBERT buscando a droga debaixo de um veículo Ford/Verona para entrega ao comprador. O terceiro atuava como 'olheiro', vigiando o local. O policial Fabio acrescentou que os réus e comparsa se revezavam na execução de tais tarefas.

Diante da suspeita conduta, aproximaram-se dos réus e do comparsa para realizar a abordagem. Ao notar a presença policial, eles fugiram.

Durante a fuga, JONATHAN dispensou porções individuais de crack.

Foram ao encalço dos agentes e conseguiram deter JONATHAN e ROBERT. O terceiro logrou fuga.

Realizada a abordagem, localizaram em poder de JONATHAN a quantia em espécie proveniente do tráfico de drogas (R\$ 30,00).

Diligenciaram nas imediações do local dos fatos e debaixo do veículo Ford/Verona que estava próximo dos acusados, durante a ação criminosa, localizaram porções individuais de cocaína e crack.

JONATHAN admitiu a propriedade da substância entorpecente. ROBERT negou o seu envolvimento no tráfico de droga.

Foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia.

Durante o percurso do ponto de droga até a sede policial, ROBERT, 'muito alterado', aparentemente sob efeito de substância entorpecente/álcool, passou a afirmar que era 'ladrão' e mataria a namorada, pois acreditava que tinha sido denunciado por ela. Falava palavrões e proferia ameaças.

Na Delegacia de Polícia, ROBERT, agressivo, continuava a proferir ameaças, xingamentos e deu socos na parede.

Mais calmo e após ter sido alimentado, ROBERT foi levado para realizar a identificação datiloscópica, momento em que, de inopino, agarrou a cintura do policial Fabio. O réu ficou com o braço e a cintura por cima da arma de fogo da testemunha, demonstrando que a sua intenção era tomar para si o instrumento. Neste momento, o policial Fabio machucou o braço, que 'virou' e ficou travado entre o réu e sua perna.

Fabio foi firme ao apontar que o réu não agiu 'deliberadamente' para machucá-lo.

Quando o agarrou para pegar a arma, o seu braço acabou torcido.

Diante da situação, foi necessária a utilização de força moderada para conter ROBERT.

O policial FABIO ainda esclareceu: Havia outros policiais na Delegacia de Polícia, mas no momento da legitimação só estava na companhia da testemunha Fabiano. Teve que dar 'cotovelada' e um forte empurrão no réu para dele se desvencilhar. Havia, ainda, o risco de que o acusado tomasse a sua arma de fogo. Teve que agir rapidamente.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.1996 - p. 39.846).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas (RDTJRJ 7/287).

Os policiais não conheciam os acusados e não tinham razão para narrar dinâmica diversa da verdadeiramente praticada na data do fato.

Salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade dos policiais, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testigos que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Não há contradições aptas a retirar a credibilidades dos informes policiais, ao contrário do ventilado pela defesa em debates, pois se complementaram nos pontos essenciais para demonstração das elementares do tipo penal e autoria.

Outrossim, inexistiu o mínimo indício de que os policiais tivessem qualquer motivo para colocar em risco as suas carreiras forjando uma situação prejudicial ao réu, que sequer conheciam, imputando-lhe falsamente crime.

Nesta linha:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (TJSP, rel. Osni Pereira, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16ª Câmara Criminal, julgado em 27/01/2015). Quanto à ausência de qualificação de testemunhas civis ou usuários de droga, o policial Fabio explicou ter sido priorizada a prisão dos traficantes para não prejudicar a operação.

Certo é que, além da harmônica prova oral acusatória, a variedade e a espécie de substância entorpecente apreendida (36 eppendorfs contendo cocaína e 99 eppendorfs contendo crack), a forma como acondicionada (individualmente), a apreensão de dinheiro trocado e as circunstâncias da prisão (atitude suspeita em local conhecido pela prática da mercancia ilícita e fuga), tornam evidente que a droga se destinava ao consumo de terceiro.

Tais circunstâncias constituem elementos relevantes para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, conforme preconiza o artigo 28, §2º, do citado Diploma.

Consigne-se que, embora os réus não tenham sido presos enquanto efetuavam a venda da droga a terceiro, tal circunstância, por si só, não afasta a imputação feita na denúncia. Isso porque o crime de tráfico, como delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, consuma-se com a ocorrência de qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, dentre as quais se insere aquela imputada aos

acusados na denúncia, sendo suficiente a identificação da finalidade mercantil. Não militam quaisquer excludentes de ilicitude ou dirimentes em benefício do acusado, ausente prova nesse sentido.

ROBERT se declarou usuário de cocaína e bebida alcoólica. Ainda que adotada como verdadeira (os policiais confirmaram que o agente estava alterado e o vídeo acostado aos autos traz fortes indícios neste sentido), a premissa não tem o condão de afastar a culpabilidade do réu.

Em Juízo, o acusado não apresentou qualquer indicativo que revelasse estar sua capacidade cognitiva comprometida em razão do uso de entorpecentes. Pelo contrário, revelou-se lúcido e eloquente, relatando sua versão dos fatos de forma concatenada e segura, afastando, inclusive, o crime que lhe foi imputado.

Outrossim, preso desde junho de 2021, o réu não declarou alteração comportamental ou de saúde típica de quadro de dependência química. Ao contrário, afastou-a, afirmando que ingere álcool e cocaína apenas quando tem alguma discussão com a companheira ou família.

Conforme preceitua o art. 28, II, do CP, a embriaguez, voluntária ou culposa, ausente prova em sentido contrário, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. No referido dispositivo legal, o Estatuto Repressivo adotou a teoria da *actio libera in causa*, “segundo a qual, considera-se imputável quem se põe em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, seja dolosa ou culposamente, e nessa situação comete o crime” (TJMG, AC1.0352.03.007518-3/001, Rel. Des^a MARIA CELESTE PORTO, DJ 24/2/2007).

Saliente-se que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante.

É sabido que, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da droga. Não descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a Polícia haver apreendido pequena quantidade do tóxico em poder do réu” (STF 1^a T. HC n. 74.420-6/RJ Rel. Min. Celso de Mello DJU de 19.12.96, p. 51.768).

Em relação a JONATHAN, duas justificativas foram ofertadas para a prática da mercancia ilícita: Dificuldade financeira (aduziu que estava desempregado na fase policial) e coação (afirmou, em Juízo, que devia aos traficantes e para quitar a dívida foi obrigado a trabalhar na 'biqueira').

Não está demonstrado o estado de necessidade. A dificuldade financeira, por si só, não configura a discriminante. Há que se comprovar não apenas a miserabilidade, mas também que a conduta criminosa foi a derradeira para a sobrevivência do agente ou de sua família, sob pena de se acolher a prática criminosa como meio de vida. De tal ônus o réu não se desincumbiu a contento.

Inexiste nos autos prova da situação de extrema necessidade da acusado, muito menos que agira visando proteger-se de perigo atual e inevitável que não tenha dado causa, elementos mínimos necessários para acolhimento da excludente, não se desincumbindo, portanto, do ônus insculpido no art. 156 do Código de Processo Penal.

Eventual dificuldade financeira, que nem sequer foi provada, não autoriza, de per si, a prática de crimes ou é hábil a configurar a excludente de ilicitude. O acusado teria condições de encontrar qualquer outra forma lícita para a obtenção para sua subsistência, como a grande maioria da população necessitada, composta por pessoas de bem.

Nessa linha:

"(...) Nesse diapasão, a despeito da falta de oportunidade e da situação de penúria a que parte da população está submetida, esse fato não pode ser utilizado como justificativa de inocência para aquele que sucumbe à tentação do ganho fácil, por cupidez ou qualquer outro motivo, enveredando pelos caminhos tortuosos da vida criminosa. Reconhecendo essa conduta como excludente da ilicitude pela ausência de um dos seus elementos, além de precedente extremamente perigoso, traria total desesperança aos milhões de brasileiros, também desempregados, que pautam suas vidas pelos princípios da dignidade, ética e moralidade. Essas pessoas saem todos os dias de casa em busca da sobrevivência honesta, não se valendo do desespero como justificativa para a prática de delitos.

Logo, o fato de estar alguém desempregado e passando por dificuldades não autoriza a afrontar o ordenamento jurídico, tampouco subsume-se à hipótese de estado de necessidade. Portanto, à míngua de qualquer prova do alegado, rejeita-se o argumento de defesa (...)" (TJSP Apelação Criminal nº 0001530-84.2017.8.26.0441, Primeira Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, j. 08.04.2019).

"(...) A par disso, não se comprovou a impossibilidade, de acordo com as circunstâncias concretas, de o apelante atuar de acordo com o ordenamento jurídico, como sustenta a Defesa, não bastando a mera alegação de que estava "desesperado", pois tem um filho pequeno e o pagamento de suas contas de aluguel, água e luz estava atrasado, para justificar o sacrifício do bem jurídico em questão. Em suma, era plenamente exigível do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu favor(...)" (TJSP Apelação Criminal nº 01508960-65.2020.8.26.0228, Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Leme Garcia, j. 04.02.2021).

Também não demonstrada a coação moral irresistível (o réu alegou que devia aos traficantes).

Segundo a doutrina, a coação existe quando há o emprego de força física ou de grave ameaça para sujeitar o sujeito à prática do ilícito, de modo que não há culpabilidade pela não exigibilidade de conduta diversa.

Na coação moral – tese defensiva – existe a ameaça, de modo que a vontade do coacto não é livre, embora possa decidir pelo que considere para si um mal menor, não lhe sendo exigível comportamento diverso.

Em qualquer hipótese, porém, exige o art. 22 do Código Penal, para excluir a culpabilidade, que a coação seja irresistível, inevitável, insuperável, inelutável, atual, ou seja, uma força a que o coacto não pode subtrair-se ou enfrentar.

Portanto, é indispensável que no caso concreto se examinem as condições de resistibilidade do coacto, levando-se em conta a gravidade do mal prometido, relevante e considerável, bem como suas condições pessoais (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código Penal Interpretado, Atlas, 7ª Ed., p. 105/106).

No caso em tela não ficaram demonstrados os requisitos legais de tal dirimente.

O acusado não explicitou a verdadeira ameaça por dívida de droga, que no mais não encontra respaldo em qualquer elemento de prova carreado aos autos, ônus que incumbia ao réu (CPP, art.156) e do qual não se desincumbiu a contento.

A propósito:

"A alegação de coação irresistível exige demonstração de prova indubitosa a cargo da Defesa, sendo insuficiente para elidir a acusação a simples argumentação de sua ocorrência, resumindo a existência do coator para quem é transferida a responsabilidade criminal" (RJTACRIM 55/78).

"Para ser aceita como excludente de culpabilidade, a coação moral irresistível deve ser substancialmente comprovada por elementos concretos existentes no processo, não bastando a simples alegação dos réus, especialmente quando a descrição dos fatos por eles fornecida encontra-se rebatida por prova em contrário" (TACRSP, RT 813/596).

"A alegação de coação irresistível exige demonstração de prova indubitosa a cargo da Defesa, sendo insuficiente para elidir a acusação a simples argumentação de sua ocorrência, presumindo a existência do coator para quem é transferida a responsabilidade criminal" (RJTACRIM 55/78).

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico de droga pelos réus ROBERT e JONATHAN. Em relação aos delitos de desacato e lesão corporal dolosa imputados ao réu ROBERT, a absolvição é a medida escoreta.

Os policiais civis afirmaram que o agente proferiu xingamentos e ameaças dirigidas à equipe policial, conduta que teria sido filmada com uso do aparelho celular de um deles.

Todavia, como bem apontado pelo Ministério Público em debates, o vídeo (link a pág.100) acostado aos autos deixa dúvida se os dizeres do acusado (xingamentos) foram proferidos com a intenção de humilhar e desprestigiar a função exercida pelos policiais. O réu diz que é 'assaltante', ameaça a companheira, fala palavras aleatórios e demonstra evidente alteração por uso de substância entorpecente ou álcool.

Não ficou demonstrado, de forma cabal, o delito de desacato.

No tocante ao crime de lesão corporal dolosa, não há dúvida de que o braço do policial Fabio ficou lesionado (cf. laudo de exame de corpo de delito de págs.149/150).

Contudo, destaca-se a fala do próprio policial civil Fabio em audiência. A testemunha afirmou que, ao agarra-lo pela cintura, o agente agiu como se tivesse a intenção de apanhar a sua arma de fogo, não querendo 'deliberadamente' (dizeres do próprio policial, que afastou o dolo) machuca-lo.

A dinâmica relatada pelo policial Fabio não permite conclusão exata sobre o dolo do agente. A dúvida deve ser interpretada em favor de ROBERT.

Se de um lado as declarações de Robert, em relação a estes específicos crimes, não se revestem de verossimilhança, de outro as demais provas careadas aos autos não permitiram esclarecimento confiável acerca do elemento subjetivo.

Ao cabo da instrução, persiste dúvida no espírito do julgador quanto à autoria.

Há indícios, não se olvida, de autoria. Todavia, é perfilhado o entendimento jurisprudencial no sentido de que os indícios autorizam a condenação se houver o concurso das condições seguintes:

a) que os elementos materiais do crime estejam plenamente provados; b) que, em recíproco apoio por prova inequívoca e concludente, incriminem o acusado, importando a exclusão de qualquer hipótese favorável a este (RT 169/76), o que não ocorre plenamente na hipótese dos autos.

Ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o dolo do agente.

Assim, a absolvição por insuficiência probatória é de rigor.

Portanto, os réus realizaram conduta típica, antijurídica (art. 33, caput, a Lei nº 11.343/06) e, em face de sua culpabilidade, impõem-se-lhes a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis aos acusados. A quantidade da droga apreendida não pode ser olvidada nesta etapa da dosimetria.

O quantum de droga apreendida (99 eppendorfs contendo crack, e 36 eppendorfs contendo cocaína), demonstra o devastador resultado que a conduta dos increpados provocou no meio social.

Relevante esclarecer que o Col. Supremo Tribunal Federal, inclusive, exarou o

entendimento de que a “natureza” (ou “qualidade”) e quantidade do entorpecente destinado à comercialização configura critério hábil para a exasperação da pena dos traficantes (“HC 94655/MS MATO GROSSO DO SUL, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 19/08/2008, Primeira Turma).

O legislador brasileiro, ao instituir a norma do artigo 42, da Lei 11.343/06, impôs aos juízes o dever de ponderar, no momento da fixação das penas dos delitos previstos nessa lei especial, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, e isto com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal”.

Saliente-se que a quantidade de droga constitui motivo idôneo para o aumento da pena-base, não sendo considerado elemento intrínseco ao tipo penal, haja vista ter o próprio legislador destacado tais diretrizes no referido artigo 42, da Lei nº 11.343/06, em razão da possibilidade de atingir montante significativo de usuários e colocar ainda em maior risco o bem jurídico tutelado, qual seja a saúde pública. Nesse sentido:

“Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” (STJ, AgRg no AREsp 1.509.839/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DEJ 18/06/2020).

A cocaína, na forma de pó ou pedra, tem alto potencial ofensivo, gerando maior probabilidade de provocar dependência química, atingindo com mais vigor a saúde pública, bem jurídico protegido pelo legislador. GRAVE é a consequência do crime, que é de perigo abstrato.

Tais circunstâncias denotam periculosidade acentuada e diferenciada, bem como conduta social avessas aos preceitos que presidem a convivência em comunidade. Sobressai-se maior grau de censurabilidade na conduta dos agentes.

Em relação a ROBERT, também devem ser consideradas as desfavoráveis condições subjetivas.

Ostenta condenação anterior e definitiva pelo crime de roubo (auto nº 0026377014.2013 – 2ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 2014. Pena extinta pelo cumprimento em 2017, cf. certidão criminal de págs.61/63, F.A a págs.64/70 e certidão de objeto e pé às págs.170/171).

Ainda deve ser considerada a má conduta social apresentada pelo agente, que cumpria pena definitiva e anterior por outro delito de roubo, em regime aberto. Não obstante, desconsiderando a confiança que lhe foi atribuída pelo Estado ao ser colocado em liberdade mediante condições, voltou a delinquir, praticando crime equiparado a hediondo.

Não se trata de simplesmente considerar condenação anterior e irrecorrível. É diferente a situação do réu que cumpriu integralmente a pena anterior e, no prazo da prescrição da reincidência, volta a delinquir, daquele que ainda cumpre a reprimenda (regime aberto, livramento condicional ou saída temporária, por exemplo) e reitera a prática de crime.

É maior a reprovabilidade da conduta do agente na segunda hipótese, demonstrado a opção pelo crime como meio de vida, periculosidade diferenciada e menoscabo pelas determinações judiciais.

Nesta última situação o acusado deve ser apenado com mais rigor, sob pena de inobservância do princípio isonômico e da mais adequada individualização da pena em cada caso concreto.

Apresentando conduta ainda mais censurável, no trajeto do ponto de droga à Delegacia de Polícia, o acusado proferiu xingamentos e ameaças, agindo agressivamente contra a equipe policial na Delegacia de Polícia, demonstrando ausência de freio e conduta social não consoante à moralidade média.

Assim, fixo a pena-base dos acusados acima do mínimo legal. Considerando a quantidade de droga, as nefastas consequências da conduta (crime de perigo abstrato), as circunstâncias da prisão e as condições subjetivas acima apontadas, elevo em 1/6 a reprimenda de JONATHAN, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa; e em 1/4 a pena base de ROBERT, o que perfaz 06 anos e 03 meses de reclusão e pagamento 625 de dia-multa.

Aumento mínimo ou em fração menor da acima estipulada não atende as finalidades da sanção penal, pois o caso se diferencia dos demais similares, sob pena de inobservância do princípio isonômico e da mais adequada individualização da pena em cada caso concreto.

Reincidente (autos nº 0000245-25.2018 - 1ª Vara Criminal de Diadema. Trânsito em julgado em 2019, ainda em cumprimento de pena, cf. certidão criminal às págs.61/63), elevo a pena de ROBERT em 1/6, o que perfaz 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 729 dias-multa. Não incidem atenuantes. A seguir, verifica-se a reincidência de JONATHAN (autos nº0000356-43.2017 - 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 2018, cf. certidão criminal às págs.54/56 e certidão de objeto e pé a pág.156) e atenuante da confissão espontânea (os seus dizeres também foram considerados como elemento de convicção para a condenação), operando-se a compensação. Há orientação do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo sobre o assunto, a qual deve ser observada pelos Juízes e Tribunais (artigo 927, inciso III, do novo Código de Processo Civil).

A tese aprovada na ocasião foi a seguinte: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência” (Tema 585, REsp 1341370/MT, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, julgado em 10/04/2013).

Ademais, em data recente, estabeleceu-se que a compensação seria integral pelo simples fato de serem ambas igualmente preponderantes: “A Terceira Seção, em 23/05/2012, por ocasião do julgamento do EResp n. 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, pacificou o entendimento, segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, deve ser compensada com a agravante da reincidência. Precedentes” (AgRg no REsp 1557243/RN, Min. Rel. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 28/06/2016, v.u.).

Não se aplica a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, não preenchidos os predicados legais. Os réus são reincidentes.

O valor de cada dia-multa será calculado no valor unitário mínimo e atualizado desde a data da infração.

O regime para o início de cumprimento de pena é o fechado. Mostra-se adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a gravidade CONCRETA do delito de tráfico, circunstâncias em que foi praticado e suas consequências, que demonstram a periculosidade e ousadia dos agentes, aptas a reclamar reação severa, proporcional e seguramente eficaz, sob pena de impunidade. Inexiste relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. Os réus são REINIDENTES em crimes dolosos e graves. JONATHAN é reincidente específico.

ROBERT ostenta duas condenações anteriores e irrecorríveis por crime de roubo. Ainda cumpria uma das reprimendas em regime aberto quando voltou a delinquir. Tais circunstâncias denotam periculosidade acentuada e diferenciada, bem como conduta social avessas aos preceitos que presidem a convivência em comunidade, sujeitando os acusados à modalidade mais severa. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, não preenchidos os requisitos subjetivos do artigo 44 do Código Penal.

Note-se que o próprio artigo 44 do Código Penal estipula casos específicos em que não é permitida a substituição da pena, obstando a concessão do beneplácito legal a casos em que a substituição não tem o condão de alcançar os fins colimados com a aplicação da pena e da lei penal.

E neste ponto, a aplicação de uma medida tão branda e complacente vai de encontro ao tratamento austero e rígido que vem expresso pelo ordenamento jurídico brasileiro, principalmente quando se trata, como apurado nos autos, de atividade vinculada à criminalidade organizada, afastando-se a figura do tráfico privilegiado.

Neste sentido, a Constituição Federal reserva tratamento especialmente severo ao tráfico ilícito de entorpecentes nos artigos 5º, inc. XLIII e LI, e artigo 243, parágrafo único.

Assim, a impossibilidade de se aplicar a substituição ao grave crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que tanto assola a comunidade, fica evidente com a interpretação sistêmica do ordenamento jurídico nacional, concluindo-se pela vedação como reflexo esperado ao tratamento mais rigoroso dado pela Constituição da República e pela legislação ordinária ao crime de tráfico de drogas.

Resulta ilógico substituir penas privativas de liberdade para impor sanções restritivas de direitos a condenados por crimes hediondos e equiparados, sob pena de esvaziar-se o tratamento rígido que a Lei buscou propiciar a fim de concretizar a política criminal voltada a dirimir a traficância de entorpecentes, que, a propósito, envolve sempre outras práticas delitivas execráveis que tanto devastam o país.

Também não é cabível a suspensão condicional da pena (CP, art.77). A concessão de tal benesse descaracterizaria a eficácia intimidante da pena e constituiria incentivo à reiteração da conduta, a par de não preenchidos os requisitos legais. A Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, para permitir que o Juiz desconte na sentença o tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação no total de pena imposta, o que se dá unicamente para fins de fixação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Ocorre que referida alteração apenas tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência, o que não se vê patenteado no caso em tela.

Ainda que se entenda que o tempo de prisão processual deva ser descontado para a aplicação do artigo 33, §2º, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em razão do quantum, mas pela maior reprovabilidade da conduta dos agentes e suas desfavoráveis condições subjetivas, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal. Há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a modalidade mais gravosa.

Acerca do assunto, merece destaque o seguinte julgado emanado do E. TJSP, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a detração:

“Finalmente, é inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria” (TJSP - 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 - Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão no Juízo da Execução.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar os acusados:

a) JONATHAN HENRIQUE ANTUNES MARTINS, qualificado a pág.41, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena de

05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.

b) ROBERT JOSÉ DA SILVA, qualificado a pág.36, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 729 dias-multa, no valor unitário mínimo. E ABSOLVO-O da prática dos crimes previstos nos artigos 129, caput, e 331, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pelas razões expostas alhures.

Os réus responderam ao processo presos (convertida a prisão em flagrante em preventiva – págs.85/88).

Em que pese a excepcionalidade da custódia cautelar, a medida ainda é necessária para o atendimento da finalidade da persecução penal.

Presente o fumus comissi delicti, consubstanciado nas declarações dos policiais civis e na presente condenação. O periculum libertatis evidencia-se não apenas pela gravidade CONCRETA da conduta imputada aos agentes, mas pelas desfavoráveis condições subjetivas que apresentam, a demonstrar a ineficácia das medidas cautelares para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Não se trata de presunção genérica de periculosidade de indivíduo assim acusado. Cuida-se de constatação cotidiana, reforçada pelo legislador pátrio: O tráfico de drogas é atividade que denota a criminalidade organizada; a disseminação das drogas impõe aos usuários a prática de delitos antecedentes, contra o patrimônio alheio, para sua aquisição, e de delitos posteriores, geralmente contra pessoas, em razão da alteração do estado psíquico decorrente de seu consumo.

JONATHAN ostenta recente condenação definitiva justamente pelo crime de tráfico de droga. ROBERT ostenta duas condenações recentes e definitivas por delito de roubo, sendo que ainda cumpria uma das penas em regime aberto quando voltou a delinquir. Os réus adotaram a prática de graves crimes como meio de vida. Há fortes indícios de que, em liberdade, voltarão a delinquir.

Não se cuida, portanto, de apenas um desvio na vida dos réus, que assim ostentam periculosidade acentuada e diferenciada, bem como conduta social avessas aos preceitos que presidem a convivência em comunidade.

As medidas cautelares previstas na legislação processual penal não se mostram adequadas e suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo imprescindível para eficácia da persecução penal a manutenção da custódia cautelar.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o réu não poderá apelar em liberdade. Expeça-se o necessário e recomende-se cada acusado na prisão onde se encontra recolhido.

Em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Inexiste prejuízo aos sentenciados quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019) e não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência.

Considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar nesta sentença, há inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019).

Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Em relação às lesões corporais atestadas no documento de pág.50 e no laudo de exame de corpo de delito de pág.148, os policiais civis informaram que o réu Robert, no interior da Delegacia de Polícia, quando se iniciava o procedimento de legitimação para identificação criminal (portanto, quando estava sem algemas), de inopino agarrou a cintura do policial Fabio e agiu como se tivesse buscando tomar para si a arma de fogo da testemunha. Pouco antes, esmurrou paredes da Delegacia. O vídeo (link a pág.100) mostra que o acusado agia sem freio inibitório no interior da viatura policial, no trajeto entre a 'biqueira' e o Distrito Policial, proferindo xingamentos, declarando-se 'assaltante' e ameaçando a companheira.

O agente estava alterado pelo uso de álcool e/ou substância entorpecente. Nesta situação fática Robert agarrou o policial Fabio. Os agentes da lei tiveram que agir e declararam uso de força moderada. A testemunha Fabio admitiu ter desferido cotoveladas no rosto do agente, rapidamente, a fim de se desvencilhar de Robert e evitar que tomasse a sua arma de fogo.

Neste contexto, não vislumbro, de plano, abuso pelos policiais civis. No entanto, por cautela, a pedido da Defensoria Pública, diante das lesões corporais verificadas no réu, submeto o caso à análise da Corregedoria da Polícia Civil. Oficie-se com cópia da presente sentença.

Decreto o pedimento do dinheiro apreendido, oriundo do tráfico de droga, em favor da União.

De plano, não tendo havido controvérsia sobre a natureza ou quantidade da substância entorpecente, bem como sobre a regularidade do respectivo laudo químico-toxicológico, oficie-se à Autoridade Policial para destruição das substâncias entorpecentes apreendidas nos autos;

Após o trânsito em julgado desta sentença:

- a) lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, expedindo-se guias de recolhimento definitiva;
- b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação dos réus, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;
- c) Calcule-se a multa, intimando-se, em seguida, os réus para que procedam ao pagamento;
- d) Providencie-se a transferência do numerário depositado nos autos para a conta do FUNAD e oficie-se à SENAD, informando sobre a decretação do perdimento da quantia apreendida e o local do depósito.

Custas pelos réus no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03. A exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA